

最高裁判所御中

過少申告と遁脱（平成13年（あ）第1128号事件）に関する意見書

三木義一（立命館大学教授）
（法学博士・一橋大学）

2002年6月5日

一 意見書の趣旨

本意見書は、本件の中心的争点である①圧縮記帳引当金処理及び②貸倒処理に伴う過少申告が遁脱の構成要件である「偽りその他の不正の行為」に該当するかについて、長年税法を研究してきた者として意見を申し述べるものである。

二 原審の判断

原審である広島高等裁判所松江支部平成13年6月11日判決は、上記争点について次のような判断を示している。

まず、①圧縮記帳引当金処理の問題については、「真実の所得を隠蔽し、それが課税対象になることを回避するため、所得金額をことさらに過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為自体が同項（法人税法159条1項）にいう『偽りその他の不正の行為』にあたる」と述べ、「同処理に遁脱の故意を認めるに十分」と簡単に退けている。

また、②の貸倒処理の問題についても、光栄水産の事案につき「同（＝山根）被告人が被告人小汀に光栄水産に対する未払賃料債権について貸倒処理するよう指示した経緯等は原判決説示の通りであり、これによれば被告人山根に同貸倒処理につき遁脱の故意を認めるに十分」であると判示し、市原畜産については、一審判決の事実認定と故意の認定をそのまま認定している。なお、一審判決は貸倒処理につき、両事案についての事実認定をした上で「以上の事実並びに被告人山根の公認会計士及び税理士としての長年の経歴と実績を総合すると、被告人山根は、被告人小汀に対し本件未収貸金債権について貸倒れ処理をするように指示した際、本件未収貸金債権につきその全額が回収の見込みがないわけではないことを承知の上で、被告人小汀が作成した当初の合計残高試算表上の被告人組合の当期利益を消滅させる目的で右貸倒れ処理をしたものと推認するに十分」であるとしている。原審及び一審判決がこのような簡単に遁脱の故意を認定している背景には「真実の所得を隠蔽し、それが課税対象になることを回避するため、所得金額をことさら過少に記載した内容虚偽の確定申告書を税務署長に提出した場合には、右のような虚偽の過少申告を内容とする確定申告書を提出する行為自体が法人税法159条1項にいう『偽りその他の不正の行為』に該当する」という理解が前提としてあり、その根拠に最高裁昭和48年3月20日判決（刑集27巻2号138頁＝以下、最高裁判決と略す）を引用しているのである。

しかし、最高裁判決を右のように形式的に理解し、本件に機械的に当てはめる理解は正しいのだろうか。

三 最高裁判決の形式的理解と法治主義

原審等が前提としている最高裁48年3月20日判決は確かに次のように判示している。

「真実の所得を隠蔽し、それが課税対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を税務署長に提出する行為（以下、これを過少申告行為という。）自体、単なる所得不申告の不作为にとどまるものではなく（当裁判所昭和25年（あ）第931号同26年3月23日第二小法廷判決・裁判集刑事42号登載参照）、右大法廷判決の判示する「詐偽その他不正の行為」にあたるものと解すべきである。」

上記の最高裁判決を形式的に理解すると、原審のように、意識的な過少申告をすべて「偽りその他不正な行為」と解しうる可能性もあるように思われる。しかし、最高裁判決をそのように理解するのは誤りであるし、そのような理解は法治国家及び権利救済制度の前提を覆すものになってしまう。このことを少しわかりやすく説明したい。

まず、前記最高裁判決で問題となった過少申告は、被告人がA社から約4300万円受領したものの、A社においても所得として管轄税務署長に申告しないいわゆる簿外金から出金されたものであることを知りつつ、当該金額を記載しないまま虚偽の申告を行ない、約2300万円の所得税を免れようとした事案である。このケースで、被告自身は確かに積極的な所得秘匿行為はしていないが、A社の簿外資金化に対応した行動であり、しかも、被告人の申告行為からはA社の支払い事実や被告人自身の真の所得は全く表れていない事案である。このような申告は、具体的な不正行為と連動しているだけではなく、申告書自体からは真実の所得は発見できない点において、「偽りその他不正の行為」に当たると判断したものであり、具体的事案との関係において妥当な判断だったと解される。

したがって、右の最高裁判決から、ことさら行った過少申告自体がすべて「偽りその他不正の行為」に該当すると判断することはできないし、また、そう解すると法治主義そのもののひいては租税権利救済制度を否定することになってしまうことに留意しなければならないのである。このことを具体的にわかりやすく述べよう。

税法はきわめて技術的な法律で具体的な運用に当たっては課税庁の通達幅をきかせているのは公知の事実であり、また、この通達が行政内部の解釈指針ではあっても、法令としての効力を有しないことも自明の理である。そこで、具体的な申告に際して、納税者が課税庁の通達上の解釈に疑問があり、例えば通達上は否定されているものの、法令を合理的に解釈すれば特別償却の対象になりうると考え、専

門家である税理士もそのように判断した場合、納税者は通達上の処理の妥当性を訴訟で争うことになる。このような場合、通常は、納税者が正しいと判断する解釈に基づいて申告をし、それを課税庁が更正処分で否定するので、当該更正処分の取り消しを求めて争うことになる。この場合、納税者や税理士の解釈を支持する学説等もあったものの、判決では結局課税庁の解釈が支持されたでしょう。この場合、納税者の行った申告はことさらに所得を過少に申告した虚偽の申告になり、納税者及び税理士は逋脱犯になるのだろうか。原審及び一審判決に従うなら、実務上特別償却の対象にならないことを意識した上で、しかも税理士としてそのことを熟知しながら、意識的に過少申告をしている以上逋脱の故意が認められることになってしまふ。これでは、わが国の租税権利救済制度は崩壊してしまう。周知のように、税務行政においては加算税制度が乱用され、訴訟で争うことを覚悟する場合には加算税負担を覚悟しなければならず、これが訴訟を断念させる一つの原因となっている（そのため、それを回避するために、申告は通達通り行った上で更正の請求を行い、その拒否通知の取消を争うという迂回手段が近時はやっているほどである）。いずれにせよ、原審の判断に従うと、納税者は課税庁の解釈を法治主義のルールに則り争うためには加算税負担と逋脱犯の危険を覚悟しなければならなくなる。これが正常な解釈なのだろうか。最高裁がこのような不合理な結論を導く判断をしていると解していいのだろうか。

四 過少申告の諸形態と逋脱

原審及び一審判決の最大の誤りは、過少申告といわれるものの具体的内容に様々な類型があるにもかかわらず、それを一律に解したことである。そのため、最高裁判決の趣旨を著しく歪めてしまったと言わざるを得ないのである。これに対して、最高裁判決の趣旨をより正確に理解するための一つの重要な手がかりを提供していると思われるのが、東京高裁平成6年11月30日判決（判例時報1541号137頁、判例タイムズ904号233頁、税務訴訟資料233号326頁）である。事案は、申告所得金額から算出される税額より過少な申告税額を記載した申告書に係わる逋脱犯の成立について判示したものであるが、最高裁判決の趣旨を次のように正鵠にまどめている。

「確定申告書にことさらに虚偽過少の所得金額を記載すること自体が『偽りその他不正の行為』に当たると解される所以は、申告納税制度の下においては、税務当局において納税義務者の課税所得を把握するには、第一次的には納税義務者の提出する確定申告書に記載された申告所得金額（その算出の基盤となる個々の益

金、損金の額を含む。また、税額控除の適用がある場合における控除理由の存在及びその額についても、所得金額に準じて考えるべきである。)によらざるを得ず、その記載に虚偽過少の疑いがあるとしてこれと異なる金額を認定するためには、法令に基づく調査、査察を経て、実際所得金額を捕捉しなければならず、そのこと自体、正しい税額の確定、徴収を不能もしくは著しく困難ならしめる契機となるからである。これに対し、確定申告書に記載する税額は、税法の規定に従い、申告所得金額から客観的に算出することが可能であって、たとえ納税義務者において申告所得金額から算出される税額より過少な税額を記載したとしても、税務当局においてその誤りを発見し、是正することは極めて容易であり、そのことによって正しい税額の確定、徴収が不能又は著しく困難になるものとは考えられない。このような税額の記載の誤りは、多くの場合、遁脱の故意に基づかない単なる計算違いに過ぎないと考えられるが、たとえそれが遁脱の故意によることさらな虚偽過少記載であったとしても、法人税法159条1項にいう『偽りその他不正の行為』の定型性を有しないものというべきである。」

この判断は、申告納税制度の趣旨だけではなく、前述の租税権利救済制度とも合致する説明である。この判示に従えば、前述のように、課税庁の通達解釈がおかしいと判断した納税者が、税理士とともに合理的と考えられる解釈に基づき特別償却を行うと、申告書及びその添付関係書類からそのような処理をしたことが課税庁も判断できるので、課税庁は納税者の判断がおかしいと考えれば更正処分を行い、それを納税者が争えば裁判所が判断することになる。仮に、裁判所は課税庁の解釈を支持したとしても、この場合は遁脱犯の成立は問題とならないことになる。仮に、納税者側の解釈が、全く合理性のない非常識な解釈であれば、このような場合にこそ加算税を適用すればよいのであって、申告書から納税者の主張が読みとれる以上、遁脱犯の成立まで問題にすることはなくなるのである。

このように、過少申告と遁脱犯の問題を検討する場合には、過少申告の具体的内容を類型化する必要があるのである。その際、遁脱犯の成立の判断に当たっての重要な判断要素は、①所得秘匿活動の有無、②過少申告の認識の有無、③申告書及び添付書類からの真実の所得発見可能性の有無、の3要素が重要である。この3要素に応じて場合分けをすると次のような諸類型が考えられる。

【第1類型】所得秘匿行為を行い、そのうえ虚偽の過少申告をし、申告書及びその付属書類からは真実の所得が発見できない場合

……この場合は、まさしく典型的な遁脱犯である。

【第2類型】所得秘匿行為自体はないが、虚偽の過少申告を行い、申告書及びその付属書類からは真実の所得が発見できない場合

……従来、最高裁判決で「偽りその他不正の行為」に該当するとされたケースは基本的にこの類型である。この場合、課税庁としては、申告書自体からは納税者の法的判断や、会計処理を判別できないので、申告の前提となる秘匿活動がないとはいえ、申告書自体において秘匿する意図がうかがえるといえよう。その意味で、このような過少申告は遁脱犯の成立を免れないと言わざるを得ない。ましてや、前記最高裁昭和48年判決のケースのように、これと他の納税者の所得秘匿活動が連動している場合には単純に所得秘匿活動がないともいえない事案となり、その意味で遁脱犯成立の可能性はより高くなる。

【第3類型】所得秘匿の認識があり、その上でことさらに（虚偽）過少申告を行うが、申告書及び付属書類を点検すれば通常真実の所得が発見できる場合

……このようなケースが実際にあり得るとすると、一般納税者が申告書自体や添付書類等から容易に真実の所得を発見されることに気づかずに、意識的に所得金額等を過少に申告するような場合であろう。この場合、課税庁は申告書を精査すれば真実の所得金額を容易に発見できるのであるから、修正申告を促すか更正処分を行い、併せて加算税を課すことで十分公正な課税関係を担保できることになる。仮に、このような場合に税理士等の専門家が関与していた場合は本当に所得秘匿の認識があるかも実は疑わしい。というのは、原審とは逆に税法及び実務等を熟知している税理士等の専門家であれば、それらの所得を過少にしたところで付属資料等から真実の所得金額が計算可能なことがわかるので、そのようなことをあえてするはずがないからである。従って、仮に所得秘匿の故意が推定されとしても、それは税法に無知な素人であり、税法専門家にはあり得ないと言わざるを得ないと思われる。

【第4類型】錯誤等により過少申告をし、申告書及びその付属書類からは真実の所得金額が発見できない場合

……この場合は、申告に際して所得秘匿の認識を欠いているので単純過少申告と解して問題ないであろう。

【第5類型】錯誤等により過少申告をしたが、申告書及びその付属書類を点検すれ

ば通常真実の所得金額が発見できる場合

……この場合は、申告に際して所得秘匿の認識を欠いているし、課税庁も申告書から容易に真実の所得が発見できるのであり、むしろ、申告に際して適切な指導があれば、加算税さえも避けられるケースである。

【第6類型】課税庁の解釈に異論があり、その正当性を問うために、課税庁の解釈に反することさらの過少申告を行い、課税庁も申告や付属資料から課税庁の見解に反することがわかり、訴訟となり、結果として、裁判等で課税庁の見解が支持された場合

……これは法治国家における租税法律関係の適法性を担保するための正当な手続であり、遁脱犯が問題になる余地はない。私見では、このような申告に対しては、仮に訴訟で納税者の見解が退けられても加算税は課すべきではないと思われるが、判例はこのような場合でも過少申告加算税を肯定してきているのが実情である。しかし、こうした過少申告が少なくとも遁脱犯の成立とつながると解された事例は、筆者の知る限り、従来なかったといえる。

五 本件の具体的適用

右の類型化に基づいて本件各過少申告につき遁脱犯が成立するかに絞って検討してみよう。まず、本件のうち圧縮記帳に係わる益金戻入処理に伴う過少申告行為は遁脱犯を成立させる「偽りその他不正の行為」に該当するのだろうか。確かに、本件の処理は租税特別措置法の規定に反していると思われる。しかし、益金を戻し入っていない事実は、確定申告書に明記されており、確定申告に際しての添付書類にも明記されている。このようなことは、課税庁が申告書等を少し調べれば容易にわかるものであり、仮に納税者側に所得秘匿の意図があつたとしても前記の【第3類型】に該当し、加算税で処理できる問題である。しかも、原審及び第一審判決とは全く逆に、通常税理士がこのことに気づいていれば、過少申告加算税という不利益が課されることは目に見えるので、必ず避けることになる。本件の場合は、税理士が当該特別措置の適用要件について訴訟で争うことを意図して過少申告をしたわけではないようであり、そうすると、当該税理士が特別措置の要件を勘違いして、安易に処理したとしか考えられない。

ちなみに、租税特別措置の適用要件等はその規定の仕方が複雑であり、しかも毎年のように変更されるので、実務家でも誤ってしまうものが毎年多数ある。特例の

対象にできたのに、うっかり通常の申告をしてしまったケースや、すでに特例が廃止になっていたのに従来のまま特例を適用し、しかも税務署も特例廃止に気づかずに、数年後、別件に係わって特例適用の誤りに双方が気づくようなことが頻繁に起こっており、筆者に対しても毎年のように救済措置について相談があるのが実情である。原審及び第一審判決はこういう租税特別措置をめぐる実務の状況をほとんど理解していないようである。

次に、貸倒処理についての原審の判断は驚きを通り越してしまう。貸倒処理については、現行法上明文規定はなく、実務では通達で課税庁側の見解が示されているにすぎず、その具体的妥当性をめぐって常に双方に争いがある問題である。いわゆる興銀事件で争われたのもこの基準をめぐってであり、しかも地裁（東京地裁平成13年3月2日判決（訟務月報48巻3号757頁判例時報1742号25頁）と高裁（東

京高裁平成14年3月14日判決）での判断も異なっているのである。原審及び第一審のような基準で判断した場合には、興銀事件の興銀関係者も遁脱犯ということになる。

本件の場合、原審及び第一審も認定しているように貸倒処理をした相手方の経営状態は経営不振で滞納等の事実があり、回収の可能性に疑問が残るものであった。

このような場合、納税者の代理人である税法専門家としての税理士は、法令の許す限り納税者に少しでも有利な判断等をしないと、善管注意義務違反を指摘されることもあるのである。したがって、貸倒処理を合理化できる余地がある場合には、できる限りその可能性を探り、場合によっては課税と事実認定をめぐって争う必要もあるのである。本件は、このような意味で【第6類型】に該当するものであり、遁脱犯の成立とは全く無関係な事案である。原審及び第一審は本件貸倒処理の相手方が貸倒のおそれが全くないもので、貸倒処理自体が荒唐無稽なものであると認定しているわけではなく、経営不振等の事実も認定しながら遁脱の成立を認めている。法治国家における税法解釈と権利救済制度を全く失念した、解釈であるといわざるを得ない。

なお、仮に、当該税理士が事実認定をめぐって争うことまで意識していないとしても、貸倒処理については申告書及び添付書類から一目瞭然で、当然税務調査の対象になり、【第3類型】に該当することになり、ここでも遁脱犯は問題にならない。

最後に今一度強調しておきたいことは、課税要件をめぐる事実認定や法解釈について納税者及びその代理人は訴訟で争う権利があり、申告納税制度の下では原

則として申告において自己の主張を行い、異なる見解を持つ課税庁が更正処分をし、その妥当性をめぐって双方が意見を戦わせ、裁判所が公平な立場から判断を示すのがわが国の税務訴訟のルールである。従って、納税者が争うためには意識的に（訴訟で破れた場合に過少申告となる）申告を行わざるを得ないのである。にもかかわらず、結果として過少申告になったことを理由に原審のように遁脱犯の成立を認めることは、裁判所自体が司法救済制度を否定することにもなりかねず、最高裁がこのような判断をしてきたとは到底考えられない。最高裁での適正な判断を期待して本意見書を終えたい。